

1506377-39.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gerdinaldo Quichaba Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... a pena. No caso, estamos diante de tráfico de drogas, cujo sujeito passivo é a saúde pública; então, transportando o mesmo raciocínio acima, entende-se que a agravante em questão somente seria aplicada se ficasse comprovado, de maneira evidente e não por argumentações gerais, que houve alguma facilidade para o agente praticar o tráfico de drogas. Ao revés, estaríamos diante ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1506377-39.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506377-39.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RICARDO LUIZ DENISE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gerdinaldo Quichaba Costa

Vistos.

RICARDO LUIZ DENISE (RG: 51772163/SP) foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei Federal 11.343/06 combinado com o artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque na data de 16 de março de 2022, por volta de 13h00, durante período de calamidade pública causado pela pandemia de COVID-19, na Rua Aurélio Brasil Ribeiro, altura do número 297, Brasilândia, nesta cidade e comarca, o agente supracitado estaria trazendo consigo e estaria guardando, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 03 (três) frascos contendo 90ml (noventa miligramas) de cloreto de metileno/diclorometano, popularmente conhecido como "lança-perfume", 18 (dezoito) porções contendo 36,1g (trinta e seis gramas e um decigrama) de tetrahydrocannabinol (THC), popularmente conhecido como "maconha", 51 (cinquenta e uma) porções contendo 28,8g (vinte e oito gramas e oito decigramas) de cocaína e 34 (trinta e quatro) porções contendo 6,1 g (seis gramas e um decigrama) da mesma substância, na forma de "crack", sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante (fl. 05), e a prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo de Plantão (fls. 46/49).

O réu foi citado/notificado (fl. 86) e apresentou defesa prévia (fls. 91/94) e a denúncia foi recebida (fl. 100).

Durante a audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas policiais; ao final, o réu foi interrogado.

O Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia, com afastamento da agravante da pandemia e aplicação do regime fechado.

A Defesa requereu a absolvição e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal; o afastamento da agravante da calamidade pública; o reconhecimento da confissão; a redução pelo tráfico privilegiado no máximo legal; a fixação de regime aberto e substituição por restritiva de direitos; e, por fim, a concessão do direito de apelar em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade delitativa está comprovada: boletim de ocorrência (fls. 06/08); auto de exibição e apreensão (fls. 18/19); laudo de constatação (fls. 23/26); laudo químico-toxicológico definitivo (fls. 78/85); bem como pelas provas orais a seguir analisadas.

As testemunhas policiais Robson Gomes da Silva e Vitor Leonardo Pereira de Oliveira Junior, em sede policial, afirmaram que estavam regularmente de serviço, e realizavam diligências pelo local dos fatos, onde sabem ser um ponto recorrente de tráfico de drogas, quando, ao se aproximarem do local, avistaram um indivíduo suspeito, que estava com um frasco de lança perfume nas mãos, entregando para uma outra pessoa, e, ao visualizar a viatura policial, jogou uma bolsa no quintal de uma residência e dispensou o frasco no chão, ao passo que o indivíduo que receberia o frasco de lança perfume saiu correndo. Narraram que o indivíduo suspeito foi abordado e identificado como Ricardo Luis Denize, que, ao ser questionado no local dos fatos, permaneceu em silêncio. Aduziram que a bolsa preta que o investigado jogou no interior da residência foi encontrada e, em seu interior, haviam mais 2 frascos de lança perfume, 51 embalagens com cocaína, 18 embalagens com maconha, 34 embalagens com crack e a quantia de R\$ 5,50 em espécie. Esclareceram que foi dada voz de prisão ao investigado e ele foi conduzido à delegacia.

Em juízo, o policial Robson narrou que o local é conhecido pelo tráfico. No dia dos fatos, como não havia carro, embicou com o carro com tudo e, ao entrar na rua, conseguiram ver um indivíduo passando algo para outra pessoa e, ao avistar a viatura, jogou uma sacola por cima do muro. Informou que inclusive encontrou um lança-perfume jogado no chão e o parceiro pulou o muro conseguindo pegar os entorpecentes, e a pessoa abordada não disse nada. Explicou que não perseguiram, pois lá é uma rua sem saída e um beco, e os indivíduos estavam num canto, porém um saiu correndo e o outro ficou, então não houve perseguição, não chegaram a correr. Esclareceu que a pessoa que estava recebendo correu, e a pessoa que jogou a sacola ficou e foi abordada. Aduziu que não lembra o que tinha dentro da sacola, lembra que eram drogas, mas não a quantidade. Respondeu que, pelo que se lembra, não havia mais pessoas no local. Asseverou que não conhecia o réu. Informou que os indivíduos estavam a uns 4 a 5 metros de distância do local onde embicaram com tudo na rua.

Em juízo, o policial Vitor narrou que o local é um ponto conhecido pelo tráfico e na data dos fatos fizeram uma incursão, entraram na rua com viatura caracterizada, e viram duas pessoas bem próximas, um dos quais jogou uma sacola na laje de uma casa. Contou que um deles correu e abordaram o outro, que ficou. Relatou que conseguiram pegar a sacola ou bolsa, não lembra bem, dentro da qual havia entorpecente. Informou que a pessoa abordada foi a pessoa que jogou a sacola ou a bolsa, não se lembra exatamente, mas lembra que ele estava segurando. Aduziu que o réu não ofereceu resistência, mas negou que era dele. Falou que não o conhecia antes. Disse que não lembra de ter localizado dinheiro, nem a quantidade de drogas. Asseverou que os indivíduos estavam a uns 6 a 7 metros do local onde entraram na rua. Informou que ele próprio foi quem pulou o muro para pegar a sacola. Respondeu que não lembra os tipos e quantidade de drogas. Falou que o réu negou, não lembra exatamente o que disse, talvez que morava por ali e só estava passando. Respondeu que chamou por algum morador da casa onde caíram as drogas, mas não havia ninguém

na casa, então nenhum morador acompanhou a localização dos entorpecentes. Respondeu que não se lembra de ninguém mais no local. Disse que lembra que era dia, mas não sabe precisar o horário.

Interrogado em sede policial, o acusado exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

Em juízo, o réu confessou que realmente jogou a sacola, que era o seu primeiro dia, e foi num momento de desespero, pois precisava pagar suas contas, pagar pensão, e precisava de dinheiro.

Diante do contexto probatório formado no curso da instrução criminal, a condenação do réu é de rigor, pois a conduta criminoso a ele imputada restou cabalmente comprovada, conforme se passará a expor.

Os policiais narraram de forma segura e coerente que estavam fazendo diligência pelo local dos fatos, que já é conhecido como ponto de tráfico, quando visualizaram o réu entregando alguma coisa para outro indivíduo não identificado e, quando percebeu a presença dos policiais, tentou se desvencilhar das drogas e jogou uma bolsa no quintal de uma residência. Posteriormente, ao recuperarem a bolsa, encontraram diversos entorpecentes em seu interior, além de uma quantia em dinheiro. Houve pequenas divergências na fala dos policiais, em juízo, mas apenas questões pontuais, nada que pudesse afetar na essência o reconhecimento da traficância.

O laudo químico-toxicológico definitivo comprova que as drogas apreendidas em posse do acusado eram: 03 (três) frascos contendo 90ml (noventa miligramas) de cloreto de metileno/diclorometano, popularmente conhecido como “lança-perfume”, 18 (dezoito) porções contendo 36,1g (trinta e seis gramas e um decigrama) de tetrahydrocannabinol (THC), popularmente conhecido como “maconha”, 51 (cinquenta e uma) porções contendo 28,8g (vinte e oito gramas e oito decigramas) de cocaína e 34 (trinta e quatro) porções contendo 6,1 g (seis gramas e um decigrama) da mesma substância, na forma de “crack”.

Ademais, a forma com as drogas estavam acondicionadas e embaladas, prontas para a comercialização para terceiros, indica a prática incontestada do delito de tráfico de drogas.

Logo, formou-se uma prova segura de autoria, não havendo se falar em insuficiências ou contradições aptas a beneficiar o acusado. Além disso, o acusado confessou o delito de forma circunstanciada, confirmando o teor das declarações das testemunhas.

Portanto, de rigor a condenação do acusado nos termos acima expostos.

Passa-se à aplicação da pena.

Antes de se adentrar na dosimetria, faz-se necessário analisar a folha de antecedentes do acusado (fls. 31/37).

Verifica-se que o réu possui uma condenação à pena de 3 anos de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade, com trânsito em julgado para a acusação em 19/02/2009. Em que pese a punibilidade ter sido extinta, em face do reconhecimento da prescrição da pretensão executória, em 17/08/2021, nota-se que essa sentença foi meramente declaratória, uma vez que, em razão da pena aplicada, a prescrição se daria em 19/02/2017. Não pode o réu, portanto, ser prejudicado pela desídia do próprio Estado que, além de não executar a pena, demorou a reconhecer a prescrição, extinguindo a punibilidade somente em data recente. Assim, transcorrido o prazo quinquenal entre a prescrição efetiva e a data dos fatos, não pode a pena anterior ser considerada para fins de reincidência.

No mesmo sentido a questão dos maus antecedentes. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado a tese de que o prazo quinquenal não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes, não afastou completamente a teoria do esquecimento, já que não retirou do julgador a possibilidade de aferir, caso a caso, as informações da vida pregressa do réu, observando-se os princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena. Neste caso em concreto, verifica-se que há algumas peculiaridades. O processo pelo qual foi condenado se refere a um crime ocorrido em 2004. Além de ser bem antigo, nota-se que o réu não respondeu a mais nenhum outro processo. Esse diferencial, o fato de ter apenas um processo desde 2004, deve ser considerado, principalmente em se tratando de uma pessoa que não conseguiu estudar,

conforme ele próprio informou, com todas as circunstâncias que a vida o apresenta. E sua confissão reforça no convencimento sobre o seu histórico de vida. Do exposto, deixo de reconhecer também os maus antecedentes do acusado.

Portanto, fixo a pena-base do crime de tráfico ilícito de entorpecentes no mínimo legal, ou seja, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no piso, porque não há circunstâncias judiciais que justifiquem seu aumento.

Na segunda fase, a agravante constante do artigo 61, II, j, do Código Penal deve ser lida com cuidado, especialmente no que se refere à expressão "ou qualquer calamidade pública". A nítida impressão que se extrai do dispositivo é de que haveria a necessidade de o réu ter alguma facilidade para a prática delitiva em decorrência de certos acontecimentos ("incêndio", "naufrágio", "inundação"). Ou seja, alguém que se aproveitando de situações de debilidade que possivelmente está a vítima num momento de "incêndio", "naufrágio", "inundação", por exemplo, deve ter agravada a pena porque foram as situações indicadas que facilitaram a realização da conduta do agente ou tornaram a vítima vulnerável. Após os exemplos expressados pelo legislador ("incêndio", "naufrágio", "inundação"), vem uma cláusula: "ou qualquer calamidade pública". Ocorre que o raciocínio teleológico do dispositivo é "ou qualquer calamidade pública" que facilite a conduta do autor, de modo que somente se ficar comprovado, no caso concreto, que a situação de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6 do Congresso Nacional e Decreto nº 64.879 do Estado de São Paulo, ambos em vigor em 20 de março de 2020) decorrente da pandemia (coronavirusdesease 19 - COVID 19) facilitou ou demonstrou certa vulnerabilidade da vítima, é que se poderá agravar a pena. No caso, estamos diante de tráfico de drogas, cujo sujeito passivo é a saúde pública; então, transportando o mesmo raciocínio acima, entende-se que a agravante em questão somente seria aplicada se ficasse comprovado, de maneira evidente e não por argumentações gerais, que houve alguma facilidade para o agente praticar o tráfico de drogas. Ao revés, estaríamos diante de verdadeira responsabilidade objetiva, o que não se admite quando se estuda a essência do Direito Penal. Então, verifica-se que no caso concreto a situação da pandemia em nada facilitou para a prática da conduta típica. Em realidade, a depender das circunstâncias do caso concreto a situação da pandemia em questão poderia até mesmo configurar uma atenuante inominada (art. 66, CP), desde que também ficasse comprovada a circunstância relevante a justificar a minorante. Pelos motivos acima, afasto a agravante mencionada pelo Ministério Público nas alegações finais.

Ainda na segunda fase, reconheço a circunstância atenuante da confissão, nos termos do art. 65, III, d, do Código Penal, mas deixo de aplicá-la porque a pena já se encontra em seu patamar mínimo. Não há agravante.

No que tange às causas de aumento e diminuição de pena, aplica-se o redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, dado que o réu é primário, porta bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas. Portanto, reduzo a pena aplicada na fração de 2/3. Não há causas de aumento de pena.

Então, a pena definitiva será de 1 ano e 8 meses de reclusão e o pagamento de 166 dias-multa, no piso.

Fixo o regime aberto para início de cumprimento de pena do réu, ante a quantidade de pena aplicada, nos termos do artigo 33, §2º, alínea c, Código Penal.

Viável a substituição da pena por restritiva de direitos ao acusado, tendo em vista a primariedade do réu e o crime ter sido cometido sem violência ou grave ameaça.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido acusatório para CONDENAR o réu RICARDO LUIZ DENISE (RG: 51772163/SP) como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. A pena privativa de liberdade deverá ser substituída por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da reclusão e pagamento de prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo destinado a entidade pública ou privada com destinação social a ser definida pelo Juízo da Execução Criminal.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade porque não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, foi fixado o regime aberto e a pena

privativa de liberdade foi substituída por restritivas.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Autorizo a destruição das substâncias entorpecentes e dos objetos apreendidos.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União, por se tratar de bem proveniente da prática de tráfico, de acordo com o art. 63 da Lei 11.343/06.

P.I.C.

São Paulo, 13 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA